

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809030-70.2022.8.14.0040

APELANTE/APELADO: JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA

APELANTE/APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, declarando rescindido contrato de promessa de compra e venda de lote, determinando a devolução de valores pagos com retenções contratuais, aplicação de taxa de fruição e possibilidade de indenização por benfeitorias. A reconvenção foi extinta sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

- (i) saber se é cabível o reconhecimento da justiça gratuita por deferimento tácito;
- (ii) saber se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição mensal;
- (iii) saber se a indenização por benfeitorias pode ser condicionada à regularização documental;
- (iv) saber se o percentual de retenção de valores pagos pode ser majorado para 25%, à luz da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita foi formulado com declaração de hipossuficiência e não foi indeferido expressamente, configurando deferimento tácito, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição mensal configura bis in idem, por ambas possuírem natureza indenizatória. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi do Tema 970 do STJ, que veda tal cumulação.

5. A indenização por benfeitorias úteis e necessárias está prevista no art. 1.219 do CC e art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79, sendo legítima desde que demonstradas em liquidação, não podendo ser condicionada exclusivamente à regularização documental, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Quanto à retenção, é razoável sua fixação em 25% dos valores pagos, conforme entendimento firmado no STJ, sendo vedada a retenção abusiva de 30% e limitada a percentuais compatíveis com os custos efetivos do vendedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Parcial provimento à apelação de Jefferson Ribeiro Braga Ferreira para:

- a) reconhecer o deferimento tácito da gratuidade de justiça;
- b) afastar a condenação à taxa de fruição mensal.

Parcial provimento à apelação adesiva de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda para:

- c) majorar o percentual de retenção sobre os valores pagos para 25%, excluída a comissão de corretagem.

Tese de julgamento:

1. "É indevida a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, por ambas possuírem natureza indenizatória, conforme a ratio do Tema 970/STJ."
2. "A indenização por benfeitorias úteis e necessárias independe de regularização documental prévia, bastando sua comprovação em liquidação, nos termos do art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei 6.766/79."
3. "É presumido o deferimento da justiça gratuita quando o pedido é instruído com declaração de hipossuficiência e não há decisão expressa de indeferimento."
4. "É razoável a retenção de até 25% dos valores pagos em contratos de promessa de compra e venda rescindidos por inadimplemento do comprador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; CC, art. 1.219; Lei 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, REsp 1300418/SC (Tema 577); STJ, AgRg no AREsp 1453487/RJ; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por **JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da **AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS** que julgou PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos de origem que L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizou a **AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE** movida por JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA, tendo por objeto contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno.

Em síntese, informa a autora ter realizado compromisso de compra e venda com a(s) partes rés. Porém, o(a)(s) adquirente (s) deixou/ram de pagar as prestações e, embora notificado(s) (a), não purgou(ram) a mora. Por isso, postula(m) a rescisão do contrato com reintegração de posse liminarmente.

Indeferida a medida liminar de reintegração de posse e adotando demais providências para o curso do processo (ID. 21716292).

Devidamente citada, Jefferson Ribeiro Braga Ferreira apresentou contestação, com reconvenção, à ação de rescisão contratual e reintegração de posse movida por L.M.S.E.

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Alegou:

- **Gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras;**
- **Proposta de acordo no valor de R\$ 12.000,00 para quitação da dívida, considerando tratar-se de sua moradia habitual;**
- **Abusividade da cláusula de retenção de 30%, por violar o CDC e impor desvantagem excessiva ao consumidor, requerendo, se mantida, a limitação a 10%;**
- **Invalidade da notificação extrajudicial, por ausência de ciência efetiva, o que inviabilizaria a rescisão contratual;**
- **Inviabilidade de cobrança das parcelas vencidas até a rescisão, por ausência de fundamento e pretensão de acordo.**

Na **reconvenção**, pleiteia:

- Justiça gratuita;
- Indenização no valor de R\$ 110.000,00, referente à construção de imóvel no terreno, com base no art. 34 da Lei 6.766/79;
- Reconhecimento do direito à moradia, por ser o único imóvel em seu nome;
- Citação do reconvindo para contestar e, ao final, a condenação ao pagamento da indenização, custas e honorários.

Requeru, ainda, audiência de conciliação caso não haja acordo espontâneo.

No Id. 21716302 , a L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou impugnação à contestação e reconvenção ofertadas por Jefferson Ribeiro Braga Ferreira, alegando, em síntese:

1. **Gratuidade de justiça: Requer o indeferimento do benefício, pois o réu não demonstrou hipossuficiência, possui imóvel avaliado em R\$ 110 mil e é assistido por advogado particular.**
2. **Rescisão contratual e reintegração de posse: Reitera a validade da rescisão por inadimplência, prevista nas cláusulas 15ª e 16ª do contrato. Sustenta a legalidade da notificação extrajudicial e que o réu permaneceu inerte após ser constituído em mora.**
3. **Validade da cláusula 16ª: Defende a legalidade da cláusula que prevê multa, retenção e taxa de fruição, com base na Lei nº 13.786/2018 (art. 32-A da Lei nº 6.766/79), rebatendo alegações de abusividade.**
4. **Indenização por perdas e danos: Pleiteia a condenação do réu pelas perdas contratuais, multas e taxas de fruição, já que sua inadimplência gerou prejuízos à autora.**
5. **Retenção de valores pagos: Defende que os descontos previstos no contrato estão em consonância com a legislação vigente, e que não há direito à devolução integral dos valores pagos.**
6. **Direito de moradia: Alega que a posse do imóvel é ilegítima após a rescisão e que não há violação ao direito constitucional de moradia.**
7. **Indenização por benfeitorias (impugnação à reconvenção): Sustenta que o réu não comprovou a existência ou utilidade das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel. Alega ausência de documentos como alvará, habite-se, projeto, laudos técnicos e comprovantes de gastos. Cita a cláusula 17ª do contrato e o art. 34 da Lei 6.766/79, para reforçar a necessidade de comprovação formal das benfeitorias para eventual indenização.**
8. **Contraproposta de acordo: Oferece quitação do contrato por R\$ 37.278,78, com validade até 26/12/2022.**

Finalmente, requer a **improcedência da reconvenção** e a **procedência** da ação, com rescisão contratual, reintegração de posse, condenação do réu às penalidades e indenizações previstas no contrato, bem como o indeferimento do pedido de indenização por benfeitorias no valor de R\$ 110 mil, por ausência de comprovação.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2 MÉRITO

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, não tendo as partes especificado ou justificado a produção de outras provas, sendo o caso de julgamento antecipado de mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Todos os fatos arguidos pelas partes são facilmente comprovados por provas documentais ou documentadas e, nos termos do art. 370, caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e no caso as provas juntadas pelas partes são suficientes ao deslinde do feito. A propósito, não há necessidade de prova pericial como requereu o contestante, porque nesta ação rescisória o contrato será extinto, então, não faria sentido revisar o contrato para logo em seguida na mesma decisão declará-lo rescindido. Se a intenção da parte é promover a revisão do contrato, então deveria reconvir ou, em vez de ficar tanto tempo inadimplente, ingressar com ação autônoma desde quando entendeu ser o contrato abusivo.

Ademais, como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia.

Consoante a jurisprudência do STJ, “no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131 [atuais arts. 370 e 371, CPC/15], em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção” (STJ - AgInt no REsp 1331721/MG, DJe 24/10/2017).

2.1 DA RESCISÃO CONTRATUAL E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Os documentos carreados aos autos evidenciam o inadimplemento contratual por parte da adquirente, fato incontroverso nos autos. A autora procedeu à notificação extrajudicial da parte requerida, conforme documentos acostados com a inicial, bem como foi regularmente citada nos presentes autos. Na peça contestatória, o réu reconhece a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, bem como o inadimplemento, embora tente atribuir à autora a culpa por sua inadimplência.

Malgrado o esforço do contestante em justificar o descumprimento de suas prestações, o fato é que o contrato não guarda vícios de nulidade, salvo a ponderação a ser feita mais a frente sobre as despesas decorrentes da inadimplência. O consentimento foi livre e consciente, sendo que há tempos a parte ré não honra com os pagamentos. Se a parte entende que há desequilíbrio contratual o caminho a ser trilhado é a renegociação da

dívida ou repactuação do contrato e, não sendo favoráveis as condições, poderia, inclusive, ingressar com revisão de contrato, e não simplesmente deixar de pagar. A correção pelo IGPM e os juros de mora estão expressamente previstos no instrumento de contrato e não existe nenhuma vedação ao seu emprego, mesmo nas relações subsumidas ao Código de Defesa do Consumidor.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica, o que não é o caso dos autos.

As teses do sonho da casa própria, do direito à moradia, da saúde financeira do réu e do contrato de adesão nem com muito esforço seriam suficientes a justificar o prolongado inadimplemento contratual. Seria privilegiar o mal pagador, a parte que descumpriu o contrato e, como quem pretendesse locupletar-se ilicitamente, permaneceu (e permanece) usufruindo do imóvel gratuitamente. Além disso, o contrato firmado entre as partes não foi de uma casa, mas de uma faixa de terreno (lote). Se o devedor, em vez de honrar com o pagamento das parcelas, preferiu reverter o dinheiro para construir uma casa em terreno alheio, então obrou sob sua conta e risco. A ré pretende ser premiada por descumprir o contrato.

O argumento de dificuldades financeiras é demasiadamente frágil, porque esbarra frontalmente nos próprios autos, quando a parte teve condições de erguer no lote uma construção sabidamente onerosa.

Ademais, os encargos da inadimplência, como juros da mora e juros compensatórios, além da multa, são perfeitamente cumuláveis, pois se prestam a reparar a parte lesada com o descumprimento contratual da outra parte.

Portanto, a insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao status quo ante, o que implica na reintegração da posse do imóvel à promitente vendedora e na devolução aos compradores dos valores por ela já pago.

Ademais, a tese da aplicação do CDC e interpretação mais favorável ao devedor não merece prosperar, porque o contrato é expresso na forma de pagamento. Desta feita, afastados todos os fundamentos da contestação, e comprovado o inadimplemento longo e inescusável, a rescisão do contrato por culpa do comprador/réu é de ordem, sendo consequência lógica do fim do contrato a reintegração de posse em favor da autora, quem também detém o domínio do bem.

Incontrovertida, portanto, a inadimplência do devedor, torna-se imperiosa a rescisão contratual e logicamente o retorno das partes ao estado anterior, o que implica, necessariamente, no deferimento da reintegração da posse no imóvel pela promitente vendedora que, segundo restou incontroverso nos autos, ainda consta como sua legítima possuidora indireta.

É o entendimento recorrente, senão vejamos:

(...)

Nessa senda, restou claramente caracterizado o descumprimento contratual (inadimplência) quando o comprador deixou de pagar o contrato, logo, a perda da posse do imóvel é inevitável.

2.2 DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS

Quanto à restituição das parcelas pagas, pacífico tratar-se de um direito garantido pelos artigos 51, II e 53 do Código de Defesa do Consumidor, devendo aplicar as normas consumeristas ao caso em comento, vez que se trata de um contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre o autor/fornecedor e o réu/consumidor.

Evidente, assim, o direito da parte ré, promitente comprador à devolução das parcelas que pagou, ainda que tenha dado causa à rescisão contratual. Embora tal possibilidade esteja prevista no contrato firmado entre as partes, as cláusulas contratuais relativas à restituição das importâncias pagas pelos compradores em caso de rescisão contratual por inadimplemento contratual, entendo que a forma de arbitramento utilizada pelo demandante é desarrazoada e prejudicial ao consumidor.

Reconhecida a resolução dos contratos de compromisso de compra e venda de bem imóvel por motivo de inadimplemento volitivo, a promitente compradora tem direito à devolução dos valores pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento.

Ainda sobre a devolução das parcelas (saldo), noto que a cláusula 16ª, § 5º, “a” do contrato estabelece que a restituição do saldo será em parcelas mensais e sucessivas, cujo número será o mesmo das parcelas já pagas pelo comprador.

A respeito da matéria, também fora submetido ao Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, a discussão que em parte tem a ver com essa questão, embora no acórdão paradigma o caso trate de contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional. O precedente pode ser usado na espécie porque a tese firmada não faz restrição e toca na forma de restituição das parcelas pagas em caso de rescisão de contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor.

Cuida-se do Tema 577 dos recursos especiais repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Assim, considerando que o contrato prevê a restituição de forma parcela, aplico a tese firmada em recurso repetitivo (Tema 577-RR/STJ), em homenagem ao disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade da cláusula, determinando que o saldo a ser devolvido deve ser de forma imediata em valor único.

Por outro lado, considerando as despesas do demandante com administração, publicidade, corretagem, entre outras, é crível que possam exercer o seu direito de retenção de parte desse valor, devendo tal quantia ser apurada com razoabilidade em cada caso.

(...)

O promitente comprador, portanto, tem direito à devolução dos valores pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de

cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o requerente exercer o seu direito de retenção, que visando manter o equilíbrio entre as partes no retorno ao estado “quo ante” e evitar enriquecimento ilícito do promissário vendedor, fixo em 10% (dez por cento) do valor a ser restituído, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras despesas administrativas.

O valor de 30% previsto na cláusula 16, §6º, letra C, do contrato firmado entre as partes não especifica a que se refere. O percentual de 30% ora fixado a título de administração contratual não inclui perdas e danos, porque abusiva a cumulação feita pela empresa autora. Logo, reduzo o valor previsto na cláusula acima referida de 30% para 10%, sem prejuízo da multa rescisória.

2.3 CLÁUSULA PENAL e PERDAS E DANOS

De fato, ao passo que a lei consumerista veda a cláusula que prevê a perda total das prestações pagas pelo consumidor, permite que seja pactuada pena para o descumprimento da obrigação pelo consumidor, a fim de se evitar os possíveis abusos.

A cláusula penal, também denominada de pena convencional tem como finalidade principal pré-liquidar danos, em caráter antecipado, quando houver inadimplemento culposos, absoluto ou relativo da obrigação, de modo que uma vez exigido o percentual pré-estabelecido a título de cláusula penal, resta evidente a impossibilidade de cumular a cobrança com outros valores a título de perdas e danos, vez que tal cláusula tem a função de prefixação de danos devidos em razão do inadimplemento do contrato. A cumulação destes incorreria em bis in idem.

No caso sub judice, os contratantes incluíram a cláusula penal de 2% do valor atualizado do contrato, com o objetivo de prefixar perdas e danos devidos em razão do inadimplemento do contrato, embora no contrato apenas conste a perda de 30% das parcelas pagas, valor evidentemente que abarca a multa rescisória, embutida na cláusula 16ª, §6º, B, embora não nominada assim.

Por outro lado, entendo inacumuláveis a cláusula penal com perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos promitentes vendedores, devendo prevalecer a mesma decisão que tem sido prolatada por este juízo, 10% de taxa administrativa e 2% de multa rescisória.

(...)

Nesse sentido, fica afastada a cumulação da cláusula penal com perdas e danos e lucros cessantes. Outrossim, no tocante à aplicação das cláusulas contratuais que estipulam os encargos a serem suportados pelo consumidor em caso de rescisão contratual (Cláusula 15ª, 16ª e 17ª), como multa compensatória no valor de 2% do valor atualizado do contrato, taxa de fruição de 0,5% incidente sobre o valor total da compra e venda, por mês, a título de aluguel, indenização por perdas e danos, bem com a forma de devolução das quantias pagas pelo consumidor no transcorrer do contrato, se mostram desproporcionais, embora se reconheça que o valor da fruição do imóvel (0,5%) seja razoável.

Contudo, quanto à multa compensatória deve o percentual estipulado contratualmente incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, por ser razoável, por ser medida mais razoável e proporcional ao caso em comento, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da requerente que terá o seu bem de volta. No mais, mantenho hígido

o contrato quanto à taxa de fruição de 0,5%, por ser favorável aos promovidos.

2.4 TAXA DE OCUPAÇÃO ILÍCITA – FRUIÇÃO

O autor sustenta, ainda, ter direito ao recebimento da indenização a título de taxa de ocupação ilícita e uso indevido do imóvel (fruição), objeto da contratação, em relação ao período em que esteve ocupado pelos compradores, contados da inadimplência.

Por fruição entende-se o proveito ou a utilização da coisa por quem detenha sua posse ou propriedade, aproveitando-lhe os produtos dali advindos.

Pois bem. Como sabido, no tocante à taxa de fruição, cumpre frisar que se trata de um aluguel cobrado do promitente - comprador pelo período em que este permanece ocupando o imóvel sem a devida contraprestação, qual seja, o pagamento total dos valores ajustados no contrato firmado.

Nesse cenário e tendo em vista que quando do ajuizamento desta demanda a requerida estava (e está) inadimplente há bastante tempo, parece-me justo o pagamento de percentual referente à fruição do imóvel, sob pena de enriquecimento indevido do devedor.

Ademais, vale acrescentar que o negócio jurídico discutido nestes autos não se concretizou por culpa da parte promovida, a qual está inadimplente com o pagamento das parcelas do imóvel.

Diante dessas considerações, tenho que neste caso, a condenação dos devedores na taxa de fruição mensal é medida que se impõe, se demonstrado nos autos a alegação fruição do imóvel.

Nesse sentido, entendo que o percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato, relativo à fruição do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes mostra-se adequado e razoável, levando-se em consideração as condições de habitação, a localização do imóvel, assim como o tempo de ocupação e o período de inadimplência.

Assim, tenho que o percentual 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês, a título de fruição do imóvel, reflete o real valor das locações no mercado de imóveis residenciais, sendo bastante justa a fixação neste percentual, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação.

(...)

Portanto, em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pelo adquirente, mesmo que o uso tenha sido apenas potencial, já que o imóvel estava em sua disponibilidade.

2.5 DA ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS

Não podemos olvidar ainda, acerca das benfeitorias úteis e necessárias, caso existentes no imóvel, conforme apontado pelo requerido em contestação. A realização de benfeitorias pode consistir na sua conservação, melhoramento ou embelezamento, e se classificam em necessárias, úteis ou voluptuárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil.

No contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora requerida, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas

benfeitorias em conformidade com a lei e o contrato.

No mais, reputo de boa-fé a posse da requerida pelo menos ao tempo em que estava adimplente, vez que outorgada mediante contrato de financiamento, celebrado com a autora, tendo o direito a ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, se demonstradas sua regularidade, em atenção ao art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79.

DA RECONVENÇÃO

A reconvenção, embora conexa com a ação principal, é demanda autônoma relativamente à ação originária, tanto que, se por qualquer razão a primeira ação for extinta sem resolução do mérito, tal extinção não afetará a reconvenção, que prosseguirá normalmente (art. 343, § 2º, NCPC). Orientado por essa ideia, o legislador previu no art. 85, § 1º, do CPC, que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, e no art. 292 exigiu-se do reconvinte a atribuição do valor da causa na demanda reconvenicional.

Portanto, apesar de inserida no bojo da contestação, a disposição dos fundamentos do reconvinte deverá seguir os mesmos requisitos da petição inicial, atentando o interesse de agir, pedido determinado, legitimidade, valor da causa e os limites do objeto da demanda.

Além disso, a reconvenção, como qualquer outra ação, sujeita-se a requisitos processuais. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, (...)

Assim, como a pretensão do reconvinte se confunde com sua própria defesa, e seus pedidos já foram objeto de análise e decisão na ação primária, A RECONVENÇÃO TEM SEU OBJETO ESGOTADO. De fato, a demanda reconvenicional era desnecessária, pois tanto a devolução das parcelas quanto a indenização por benfeitorias decorrem da rescisão do contrato. Logo, falta à parte interesse processual, devendo ser indeferida/extinta a reconvenção, o que pode ser feito de ofício, por força do art. 485, IV e § 3º do Código de Ritos.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, afasto a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 2% (dois por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se

aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à RECONVENÇÃO, extingo-a sem análise de mérito, por ausência de interesse processual, com espeque no art. 485, VI, §3º do Código de Processo Civil.

Condeno o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 5 de fevereiro de 2024.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

JUÍZA DE DIREITO

Jefferson Ribeiro Braga Ferreira interpõe APELAÇÃO CÍVEL alegando: (i) omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, que, se deferida, afastaria os honorários sucumbenciais; (ii) duplicidade na cobrança da taxa de fruição, indevidamente prevista tanto como cláusula penal quanto como taxa de ocupação; e (iii) nulidade da rescisão contratual, por ausência de notificação válida e ciência inequívoca do apelante.

Requer a reforma da sentença para afastar os encargos e manter o contrato.

L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. interpôs apelação adesiva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos. A apelante questiona:

- 1. Preliminar de nulidade por julgamento ultra petita, ao entender que a sentença concedeu indenização por "acessões", sem pedido expresso do apelado.**
- 2. Necessidade de reforma parcial da sentença para que:**
 - Seja observada integralmente a cláusula contratual que prevê retenção de 2% sobre o valor atualizado do contrato (multa compensatória) e 30% sobre o valor das parcelas pagas (custos administrativos, publicitários, perdas e danos e lucros cessantes);
 - Seja afastada a limitação de 50% na indenização pela taxa de fruição mensal (uso do imóvel), conforme previsto no contrato (0,5% ao mês do valor atualizado do contrato);
 - A indenização por benfeitorias seja condicionada à comprovação documental e regularização legal, conforme cláusula 17ª contratual;
 - Seja reconhecida a validade plena das cláusulas contratuais como ato jurídico perfeito e manifestação da autonomia privada.

Por fim, requer a reforma da sentença para aplicação integral do contrato e, subsidiariamente, a retenção mínima de 25% dos valores pagos, conforme precedentes do STJ.

A L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora apelada, apresentou contrarrazões

requerendo a manutenção integral da sentença.

Rebate os argumentos do recorrente, defendendo:

- A impossibilidade de concessão da justiça gratuita ao apelante, empresário com capital declarado;
- A legalidade da cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição, por se tratarem de institutos distintos;
- A validade da notificação extrajudicial entregue ao recorrente;
- A ausência de ilegalidade na rescisão contratual e reintegração de posse.

Ao final, requer o **desprovimento do recurso** e a **manutenção integral da sentença**.

Jefferson Ribeiro Braga Ferreira apresentou contrarrazões à apelação adesiva, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que:

- **Não houve julgamento ultra petita, pois a indenização por acessões está amparada nos autos e na realidade fática (construção de imóvel no terreno);**
- **A cláusula de multa compensatória e retenção de 30% é abusiva, e a sentença corretamente limitou os valores com base no Código de Defesa do Consumidor;**
- **As cláusulas contratuais são padronizadas e devem ser moderadas pelo Judiciário para evitar onerosidade excessiva;**
- **A indenização por benfeitorias deve ser mantida, sendo apurada em liquidação de sentença, e o próprio apelante reconheceu a existência das melhorias realizadas.**

Ao final, requer o **desprovimento da apelação adesiva** e a **manutenção integral da sentença**.

É o relatório.

Examinados os autos, impõe-se o conhecimento das apelações, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Antecipo que as razões do apelante merecem parcial acolhida, enquanto o recurso adesivo não comporta provimento.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto à justiça gratuita, assiste razão ao apelante. Consoante o art. 99, §3º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE), a ausência de decisão expressa indeferindo enseja a presunção de deferimento, desde que haja declaração de hipossuficiência, como no caso. Reconhece-se, pois, o benefício.

Cito julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO . PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração . 2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão

dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência. 3 . Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1445382 CE 2014/0069199-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRADO PROVIDO . 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo . 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido .

(STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

Afasta-se a alegação de nulidade da rescisão contratual por ausência de notificação válida. A cláusula contratual (ID. 21716272, p. 3) prevê dispensa da notificação, sendo legítima a constituição em mora pela via contratual. Ademais, o inadimplemento prolongado é incontroverso nos autos.

DA CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA

A controvérsia reside na possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal fixada em sentença.

Neste ponto, a razão assiste, em parte, ao réu/apelante.

A sentença condenou o réu ao pagamento de taxa de fruição pelo uso do imóvel e, cumulativamente, autorizou a retenção pela autora de 10% a título de multa compensatória. Embora se refiram a institutos com nomes distintos, ambos possuem uma natureza eminentemente indenizatória, visando a recompor as perdas sofridas pelo vendedor em decorrência do desfazimento do contrato.

A sentença julgou procedente a ação para rescindir o contrato de compra e venda de lote, determinar a reintegração de posse à autora e a devolução imediata das parcelas pagas, com retenção de 12% (10% administrativos e 2% multa). Condenou o réu à taxa de fruição mensal

(limitada a 50% da restituição) e reconheceu o direito à indenização por benfeitorias úteis, a ser apurada. Extinguiu a reconvenção por falta de interesse processual e fixou honorários de 10% para ambas as partes vencidas.

Ocorre que a condenação da Apelada à taxa de fruição **incorre em bis in idem**.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp nº 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Embora o Tema 970 trate especificamente da mora do vendedor, sua *ratio decidendi* — o princípio de que não se pode indenizar duas vezes pelo mesmo prejuízo — deve ser aplicada por analogia ao presente caso, que trata da inadimplência do comprador.

Assim, não pode a Autora/Apelada pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Permitir a cumulação de ambas as verbas seria impor ao consumidor uma dupla penalidade com o mesmo fundamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, que preza pelo equilíbrio contratual e pela vedação ao enriquecimento sem causa.

Desta forma, pela *ratio decidendi* do Acórdão nº 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970, verifico que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp nº 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Neste contexto, vejamos precedente da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, *in verbis*:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. **TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA**

RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04)

Logo, havendo multa convencional no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar *bis in idem*.

Nesse sentido, havendo previsão de cláusula penal compensatória, como a fixada na sentença, esta já é suficiente para indenizar a vendedora pelos prejuízos decorrentes da rescisão, sendo indevida a cobrança cumulativa da taxa de fruição.

Assim, a sentença merece reforma para **afastar a condenação do réu ao pagamento da taxa de fruição**.

DA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E DO REQUERIMENTO PARA QUE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS SEJA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E REGULARIZAÇÃO LEGAL, CONFORME CLÁUSULA 17ª CONTRATUAL

Quanto à apelação adesiva da autora, não merece provimento. Não há julgamento ultra petita, pois a indenização por benfeitorias foi expressamente suscitada na defesa e reconhecida na sentença em caráter condicionado, sujeita a prova em liquidação, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e art. 34, §1º, da Lei 6.766/79.

CC

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

No ponto que se pede que a indenização por benfeitorias seja condicionada à comprovação documental e regularização legal, conforme cláusula 17ª contratual também não assiste razão.

A exigência de regularidade documental como condição de indenização contraria os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, já que o contrato versava apenas sobre lote e não previa expressamente proibição de construção.

A propósito, o C. STJ:

CIVIL. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ART. 34 DA LEI N. 6.766/1979 - LEI LEHMANN. BENFEITORIAS E ACESSÕES. RESTITUIÇÃO À SITUAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. [...] 2. O âmago do art. 34 da Lei Lehmann é evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes,

promovendo a restituição à situação originária. Assim, embora o dispositivo faça menção apenas a benfeitorias, parece claro que abarca também acessões. 3. A ausência de alvará/licença para construir emitido pela prefeitura municipal é irregularidade que pode ser ou não sanável, a depender do caso concreto. É temerário reconhecer - de forma categórica - que a ausência de licença para construir, a ser emitida pela municipalidade, não constitui irregularidade apta a obstar eventual condenação à indenização por benfeitorias/acessões realizadas. A licença para construir é requisito imprescindível a qualquer obra realizada em terreno urbano. 4. Conforme a mais abalizada doutrina, construções realizadas sem licença da municipalidade estão em desacordo com a lei e, assim, sujeitas a sanções administrativas, as quais não podem ser imputadas ao promitente vendedor, porquanto a posse e o direito de construir haviam sido transmitidos ao promitente comprador. 5. No caso concreto, é imprescindível a verificação quanto à possibilidade de ser sanada ou não a irregularidade - consistente na ausência de alvará/licença da prefeitura para construir -, de modo a realizar a restituição das partes à situação anterior e evitar enriquecimento ilícito de quaisquer dos litigantes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1191862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014).

E os tribunais pátrios:

(...) APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO ACAREAÇÃO ENTRE PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO EM AUDIÊNCIA. NÃO VERIFICADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS APURADAS. DIREITO DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPROMITENTES COMPRADORES. BASE DE CÁLCULO DA MULTA CONVENCIONAL ESTIPULADA NO CONTRATO. RESPEITO AO PACTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I. É tranquilo o entendimento no sentido de que o magistrado pode apreciar os fatos e as provas produzidas nos autos segundo a regra do livre convencimento motivado. Assim, não há se falar que a regra contida no artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil vincula a atividade jurisdicional do magistrado e o obriga a realizar audiência para promover a acareação entre o perito oficial e o assistente técnico sempre que a parte desejar. Na realidade, em decorrência da regra do livre convencimento motivado, a atividade do sentenciante, nesse caso, é pautada pela discricionariedade que ocorrerá de modo fundamentado. II. Diante do inadimplemento culposos dos compromissários compradores, que reconhecem terem pago apenas 6 (seis) das 60 (sessenta) prestações ajustadas, o direito de resolução do contrato é medida que se impõe, resguardado o direito de retenção deste em relação às benfeitorias realizadas. III. Rescindido o contrato de compromisso de compra e venda por culpa dos compromissários compradores, a indenização das benfeitorias levantadas no imóvel, quando há na peça de defesa pedido específico a esse respeito, é devida, ficando apenas condicionada a avaliação judicial. IV. Caso as benfeitorias sejam irregulares perante o ente público municipal, é imprescindível que o laudo pericial esclareça detidamente todas as questões que envolvem a obra,

como por exemplo, se é possível a sua regularização parcial ou total, incluindo os custos a serem despendidos, se for o caso, entre outros, a teor do que dispõe o artigo 34 da Lei nº 6.766/79 (Lei Lehmann). V. A manutenção da base de cálculo do valor da multa convencional, em razão da expressa disposição contratual, atende ao princípio da força obrigatória do pacto (pacta sunt servanda). VI. Entretanto, mister que o valor do pacto acessório seja corrigido monetariamente pelo INPC desde a data em que se considerou rescindido o contrato, bem assim sofra a incidência de juros moratórios no importe de 1% ao mês também a partir do momento em que se considerou rescindido o contrato. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO (CPC): 02451243320068090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2019)

No mesmo sentido, cito julgado desta Relatora, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.

1. Descrição do caso: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, na posse do imóvel até a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote urbano, conforme art. 1.219 do Código Civil.

2. Questões em discussão: (i) Possibilidade de reintegração de posse do imóvel sem indenização prévia das benfeitorias realizadas; (ii) Alegação de violação à coisa julgada e às cláusulas contratuais por parte da agravante; (iii) Princípios do direito à moradia e da boa-fé objetiva na execução do contrato.

3 . Razões de decidir: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé é requisito para a reintegração de posse (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6.766/79), evitando o enriquecimento sem causa da parte vendedora. No caso, não se verifica violação à coisa julgada, uma vez que a decisão agravada observou o direito dos agravados à indenização por benfeitorias, conforme reconhecido em sentença anterior com trânsito em julgado. Ademais, a agravante não comprovou a inexistência ou irregularidade das benfeitorias de forma suficiente a justificar a reintegração sem indenização prévia.

4 . Dispositivo: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a manutenção dos agravados na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas.

5. Tese de julgamento: Para a reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, conforme o art. 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/79 . (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08091688920248140000 22531467, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DA RETENÇÃO DE VALORES

Da retenção dos valores pagos, o entendimento no STJ tem se firmado na seguinte situação: O promitente vendedor só poderá reter, em seu benefício, até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador, sendo que tal percentagem pode variar de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento).

No caso dos autos, a sentença autorizou a retenção pela autora de 10% a título de multa compensatória, que se mostra desarrazoado e desproporcional, por estar em desacordo com a jurisprudência do STJ, nos termos que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA DO COMPRADOR . RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP (Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI), reafirmou o entendimento de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13 .786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10 .2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1453487 RJ 2019/0047690-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

No mesmo modo, cito julgado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APELAÇÃO REJANILDE MARINHO ALVES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E A OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA . REJEITADA. QUESTIONAMENTO DISPOSTO NOS AUTOS PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA, NA MEDIDA EM QUE A QUESTÃO SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE PROVADA MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO FARTAMENTE ACOSTADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL . NECESSIDADE. CULPA DO COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DOS VALORES . 20% (VINTE POR CENTO). SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS. JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . QUESTÃO RELACIONADA A CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO E DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS NO LOTE. PREJUDICADAS. SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU EM FAVOR DA APELANTE. APELAÇÃO L .M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA . SENTENÇA EXTRA PETITA. A PARTE APELADA REQUEREU A INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS, O QUE IMPLICA NA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ORA SUSCITADA. RETENÇÃO DOS

VALORES. DEVIDA . PERCENTUAL FIXADO. ADEQUADO.TACA DE FRUIÇÃO CUMULADA COM MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . BIS IN IDEM. RECURSOSS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08042251620188140040 27944447, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, deve ser reformada a sentença, para limitar a retenção à 25% do valor pago, excluída a corretagem.

Por fim, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata, em valor único, com correção monetária pelo IGPM desde cada desembolso, conforme Súmula 543 do STJ.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS E:

I – DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA para:

- a) reconhecer o deferimento tácito da justiça gratuita;
- b) afastar a condenação à taxa de fruição mensal;

II – DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DE L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para autorizar a retenção de 25% dos valores pagos, excluído, os valores de corretagem.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11º, do CPC, em vista do provimento parcial do recursos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora